

1501693-30.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... esta arrependido. Que já foi preso por trafico de drogas na cidade de São Paulo em 2016." Em juízo afirmou: que era morador de rua devido ao uso de drogas; que confessa que entrou no imóvel que estava com portão arrombado, estava recolhendo itens para a sua reciclagem; que na grade do portão havia 2 cadeados estourados; que visualizou bens espalhados no chão; que percebeu a caixinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501693-30.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501693-30.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187619/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO,

18994711 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2225/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO esta sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, I e §4ºC, II, combinado com o art. 61, II, "j", e art. 14, II, todos do Código Penal, porque segundo narra a denúncia de fls. 01/03, no dia 12 de julho de 2021, por volta de 10h30, em ocasião de calamidade pública1, na residência localizada à Rua Progresso, nº 109, Jardim Professor Morato, Francisco Morato/SP, com rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas móveis da idosa Alzira Cayetano Rodrigues, à época com 88 anos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A decisão de fls. 49/52 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A decisão de fls. 79/81 recebeu a denúncia, determinou a citação do réu e designou audiência de instrução por videoconferência em razão da pandemia da Covid-19. O réu foi citado e ofereceu defesa às fls. 134/135

Em audiência, foi ouvida a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. O representante do Ministério Público em alegações finais pediu a parcial procedência da ação. Pede o afastamento do rompimento de obstáculo, bem como a causa da vítima ser idosa, pois este fato não era do conhecimento do acusado. Pede furto simples tentado. Pede que na primeira fase seja fixada a pena no mínimo legal; que na segunda se considere a reincidência; que na terceira fase seja reduzida a pena no mínimo pelo iter criminis transcorrido, pois o réu já estava com os bens e na iminência de deixar o imóvel. Afirma que devido reincidência não ser específica é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de Victor Hugo de Freitas Ribeiro pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requer o afastamento das qualificadoras, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 136/138).

Documentos juntados: boletim de ocorrência (fls. 11/14); Auto de exibição e Apreensão (fls. 15); Auto de avaliação (fls. 15); folha de antecedentes (fls. 75/78); certidão de distribuição criminal (fls. 118/120).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Com efeito, a prova constante dos autos forma um todo coeso e harmônico, no sentido de imputar ao acusado a prática do delito de furto simples.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas, porquanto restaram efetivamente comprovadas nos autos, mediante depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo.

A vítima ALZIRA CAYETANO RODRIGUES foi ouvida na fase policial às fls. 09, e ali afirmou: "Que é proprietária da residência local dos fatos sendo que no dia 07 de julho de 2021 deixou o imóvel para ir para a cidade de Praia Grande/SP, sendo que a referido residência ficou trancada. Que no dia de hoje, foi avisada por Antonio Carlos, via telefone, que sua residência havia sido arrombada por indivíduo desconhecido mas que havia sido acionado a Polícia Militar. Que rapidamente regressou para sua residência e constatou que as janelas estavam danificadas e haviam sido furtados alguns bijuterias bem como duas televisões, Philips e Samsung, um aparelho de telefone fixo, um rádio-relógio e três botijões de gás. Que os Policiais Militares ingressaram em sua residência, juntamente com o Sr. Antonio, e localizaram o indiciado com as bijuterias ora apreendidas em uma caixinha. Que de pronto reconhece as bijuterias como sendo de sua propriedade. Que as bijuterias estão avaliadas de R\$ 300,00 e o prejuízo não localizados em aproximadamente R\$ 2.000,00; que não possui testemunhas para arolar nem câmeras de vigilância". Em juízo afirmou: que não estava na residência e quando foi avisada que entraram na casa, deu falta de muita coisa: duas televisões e depois foi se recordando de mais coisas miúdas; que estava viajando com o filho, sendo que, este foi avisado pelo celular, dirigindo-se para o local; que arrancaram grade do vitrô; que a gaveta estava mexida; que a cafeteira e outras coisas estavam mexidas; que foram furtadas jóias e bijuterias, sendo encontradas estas últimas; que furtaram 3 relógios de pulso que estavam numa gaveta; que tomou conhecimento que a polícia prendeu alguém, mas não viu.

A testemunha MATEUS COLLAZANTE MARCELLO foi ouvida na fase policial (fls. 05) e ali afirmou: "Que estava na companhia de sua parceira de viatura Edina, quando realizavam patrulhamento ostensivo no momento em que foram acionados pelo Sr. ANTONIO CARLOS PEDROSO, o qual informou que a residência situada no local dos fatos, poderia estar sendo furtada, sendo que solicitou que os Militares o

acompanhassem ao referido imóvel. No local dos fatos acompanhando o Sr. Antonio entrou no quintal da residência, sendo que de pronto visualizaram duas janelas da residência arrombadas(quarto e banheiro), assim sendo, verificaram que o referido imóvel se encontrava revirado/desorganizado, sendo que ao efetuarem buscas no local, verificaram que o indiciado VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO tentava se esconder, o qual ao notar a presença dos Militares tentou se evadir pelos fundos do imóvel, sendo capturado na posse de parte dos pertences subtraídos da vítima. Diante do cenário, o implicado foi conduzido a esta Unidade Policial para adoção das providências legais de Polícia Judiciária. As bijuterias foram exibidas e apreendidos em auto próprio, sendo acionado exame pericial junto ao Instituto de Criminalística para o local dos fatos sendo preservado pelos Militares, vez que os Militares informam que a grade entrada do local também se encontrava arrombada." Em juízo afirmou: que estava em patrulhamento pela área central, foi chamado por indivíduo para constatar o imóvel; que haviam duas residências no mesmo terreno; que o quintal estava bem revirado e a porta de uma residência arrombada; que aos fundos, com entrada pela rua de trás os ambulantes alugam para guardar objetos; que verificando o imóvel localizou o réu subindo uma escada, com uma mochila, havendo dentro objetos como bijuterias ou jóias e itens de higiene pessoal; que o réu afirmou que entrou para localizar bens para reciclagem e realmente haviam latinhas vazias jogadas no quintal mas não se recorda o depoente se havia na mochila; que não se recorda o que o réu disse sobre os itens localizados dentro da sua mochila; que a vítima reconheceu os itens da mochila como sendo seus;

A testemunha EDINA FRANCO DE GODÓI foi ouvida na fase policial (fls. 06) e ali afirmou: "Que estava na companhia de seu parceiro de viatura Collazante, quando realizavam patrulhamento ostensivo no momento em que foram acionados pelo Sr. ANTONIO CARLOS PEDROSO, o qual informou que a residência situada no local dos fatos, poderia estar sendo furtada, sendo que solicitou que os Militares o acompanhassem ao referido imóvel. No local dos fatos Collazante acompanhando do Sr. Antonio entrou no quintal da residência, sendo que de pronto visualizaram duas janelas da residência arrombadas(quarto e banheiro), assim sendo, verificaram que o referido imóvel se encontrava revirado/desorganizado, sendo que ao efetuarem buscas no local, verificaram que o indiciado VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO tentava se esconder, o qual ao notar a presença dos Militares tentou se evadir pelos fundos do imóvel, sendo capturado na posse de parte dos pertences subtraídos da vítima". Em juízo afirmou: que não se recorda da ocorrência; que dito local e data, recordou-se do caso; que estavam em patrulhamento quando foram solicitados por parente de moradora da residência que estava vazia pela proprietária estar fora; que foram averiguar e detectaram Victor lá dentro; que a casa estava revirada e objetos espalhados na casa e terreno; que o réu estava com uma mochila com pertences da vítima, acreditando que era uma caixinha com jóias e bijuterias; que não chegaram a verificar as câmeras dos comércios vizinhos; que o indivíduo era magro, moreno claro, 1,70 ou menos de altura, cabelo estava um pouco cumprido, mal cuidado; que foi encontrado embaixo do acesso à uma escada, sendo localizado pelo parceiro; que reconhece o réu como sendo o indivíduo que estava no imóvel, tendo dito que viu o imóvel aberto e aproveitou a oportunidade e acabou recolhendo objetos jogados na casa; que não havia nenhum instrumento com o réu.

A testemunha GILMAR RODRIGUES foi ouvida na fase policial (fls. 07) e ali afirmou: "que estava na Praia Grande com a Sra Alzyra, quando tomou conhecimento que o telhado de seu imóvel estava descoberto e pediu para seu cunhado Antonio Carlos ir até o local. Esclarece que após algumas horas tomou conhecimento que Antonio solicitou apoio da Polícia Militar para que fossem no local juntos, sendo que ao chegarem na residência situada no local dos fatos, encontraram o indiciado VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO saindo de sua casa com os objetos ora apreendidos na mão, sendo então abordado por Policiais Militares os quais lhe deram voz de prisão e o apresentaram nesta Delegacia. Que não conhecia o indiciado anteriormente, sendo que verificaram que duas janelas da residência se encontravam arrombadas, sendo que o local se encontrava revirado". Em juízo afirmou: que é filha da vítima; que estava na praia com a vítima e foi informado por mensagem que haviam quebrado uma telha para o depoente recompo-la por conta das chuvas; que pediu para o cunhado Antonio

Carlos reparar, tendo este comparecido no local que constatou que a telha estava quebrada e a grade da janela do quarto estava estourada; que Antonio Carlos pediu ajuda da viatura, tendo localizado um rapaz ainda dentro do imóvel; que constataram que 2 televisões foram furtadas e tudo na casa foi revirado e jogado no chão; que do recebimento da mensagem até Antonio Carlos entrar no imóvel durou cerca de 30 minutos; que o ferro era fixado na estrutura da janela, acreditando que não fosse fácil quebrar;

A testemunha ANTONIO CARLOS PEDROSO foi ouvida na fase policial (fls. 08) e ali afirmou: "Que no presente dia tomou conhecimento através de populares que o telhado do imóvel da Sra. ALZIRA CAYETANO RODRIGUES estava descoberto a qual reside com o seu cunhado Gilmar, sendo que resolveu ir até o local para ver o que tinha ocorrido, pois possivelmente o local poderia ter sido furtado, pois a Sra. ALZIRA CAYETANO RODRIGUES estava viajando para a praia com o seu cunhado Gilmar. Que então durante o trajeto até o imóvel solicitou apoio da Polícia Militar para que fossem no local juntos, sendo que ao chegarem na residência situada no local dos fatos, encontraram o indiciado VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO saindo da casa com os objetos ora apreendidos na mão, sendo então abordado por Policiais Militares os quais lhe deram voz de prisão e o apresentaram nesta Delegacia. Que não conhecia o indiciado anteriormente, sendo que verificaram que duas janelas da residência se encontravam arrombadas, sendo que o local se encontrava revirado. Que então efetuou contato com a vítima, a qual estava viajando, tendo retornado e constatado o furto de demais objetos." Em juízo afirmou: que recebeu um telefonema do cunhado desconfiado que tinham entrado na casa; que era logo cedo, por volta das 7h; que saiu de sua casa, no caminho viu viatura da polícia e pediu apoio, tendo o depoente entrado junto com o policial masculino, ficando uma policial feminina do lado de fora; que a janela do quarto da vítima estava arrombada; que deram uma volta no imóvel e um rapaz estava subindo escada com sacola na mão; que a policial feminina quem localizou e abordou o rapaz; que soube que na sacola do rapaz estavam os objetos roubados como brincos; que da casa do depoente até a casa da vítima tem 5 minutos; que o indivíduo foi localizado na escada que fica dentro do terreno onde há a casa da vítima e de seu filho; que o terreno é todo murado, com grades e cadeados, sendo que, a perícia constatou que a grade foi rompida;

O réu VÍTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO foi interrogado na fase de inquérito (fls. 10) afirmando que: "Que é catador de material reciclável, sendo que no dia de hoje estava passando de frente a residência da vítima e visualizou a grade de entrada aberta, sendo que entrou para pegar um saco de latinha de alumínio, sendo que verificou que a janela estava aberta, sendo que pegou um saco plástico com umas bijuterias e pegou, sendo que ao dar a volta no quintal da casa, mas quando estava saindo do local, chegou diversos policiais, sendo que foi capturado. Que nega que tenha arrombado a janela da residência da vítima, apenas entrou no local para pegar latinha. Que esta arrependido. Que já foi preso por tráfico de drogas na cidade de São Paulo em 2016." Em juízo afirmou: que era morador de rua devido ao uso de drogas; que confessa que entrou no imóvel que estava com portão arrombado, estava recolhendo itens para a sua reciclagem; que na grade do portão havia 2 cadeados estourados; que visualizou bens espalhados no chão; que percebeu a caixinha e os produtos de higiene e colocou na mochila e depois se dirigiu em direção às latinhas, juntando-as nas mãos, quando deu a volta no imóvel e viu a porta arrombada, sendo que, iria entrar mas escutou vozes e acabou não entrando; que no momento em que estava subindo as escadas do imóvel para ir embora foi abordado pelo policial; que está arrependido, pois já perdeu tudo na sua vida; que estava com mochila e saco de material reciclável na mão; que no momento em que a polícia o localizou o réu já estava com a caixinha com acessórios e itens de higiene, na mochila; que estava sozinho; que não chegou a entrar dentro da casa; que é fumante e possuía maço de cigarro, cachimbo; que não se recorda de ter perdido isqueiro, pois o seu estava consigo; que possuía R\$ 5,00 produto da reciclagem.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra que o réu de fato adentrou na residência da vítima e ali furtou alguns objetos, que foram encontrados sob sua posse.

Além dos depoimentos da representante da vítima e das testemunhas, o réu confessou

o delito e mostrou-se arrependido.

Nesta esteira, considerando que os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão do réu mostrar harmônicos e condizentes com o conjunto probatório dos autos, permitindo, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelo crime furto.

Sustenta a defesa que "que o acusado apenas pegou objetos que se encontravam fora do imóvel, de pequeno ou sem qualquer valor e produtos de higiene pessoal, que apenas demonstra a necessidade do acusado, conforme provas dos autos percebe-se que havia outros bens de valor que valiam bem mais que os objetos furtados". Todavia, em que pese o baixo valor dos bens furtados, este Juízo entende que a conduta do acusado não pode ser considerada atípica, com base no princípio da insignificância. Isso porque, referido princípio surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal e, dessa forma, conforme a dogmática moderna, aludido tipo não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, para a aplicação do princípio da insignificância, não se pode levar em consideração apenas o valor subtraído. É de suma importância verificar, além deste, as circunstâncias fáticas presentes no caso concreto. Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Lembremos que a utilização do princípio da insignificância, por se tratar de causa supra legal de exclusão da tipicidade, submete-se, naturalmente, à política criminal do Estado, na hipótese sob a ótica do Judiciário. Logo, inexistem regras fixas para essa avaliação. Deve-se analisar cada caso individualmente. Nas palavras do Ministro Cezar Peluso: A indagação sobre a conveniência ou não de proteção penal ao bem jurídico de que cuida a hipótese seria matéria de política criminal" (STJ - HC 88.077-RS, 2ª T., 31.10.2006). [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: Parte Geral - Parte Especial - 4. ed. Editora RT, São Paulo, 2008, p. 690). Assim, para se considerar que a conduta do agente não resultou em perigo concreto e relevante, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal, é preciso conjugar a inexistência de dano ao patrimônio da vítima com a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, o que verifico não estar presente na hipótese dos autos, uma vez que o seu reconhecimento, no caso concreto, pode servir de estímulo à prática reiterada de infrações patrimoniais de pequena monta, ao gerar naquele que apresenta inclinação ao cometimento de delitos dessa natureza inevitável sensação de impunidade.

Destarte, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, justificando-se a imposição de sanção ao acusado. Já com respeito às qualificadoras descritas na denúncia, verifico que, de fato, não restou demonstrado nos autos que o réu sabia que a vítima era pessoa idosa, uma vez que esta, sequer encontrava no local dos fatos. Quanto ao rompimento de obstáculo, verifico que não há nos autos perícia local que demonstrasse a ocorrência da qualificadora, tampouco depoimento de testemunhas que afirmasse que foi o réu quem quebrou cadeados e grades da residência. Assim, nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal, tratando-se de circunstância que deixa vestígio, o exame pericial era imprescindível. Por tais razões afasto as qualificadoras dos § 4º, I e §4ºC, II, ambas do Código Penal.

Contudo, diferentemente do descrito na denúncia, verifico que no decorrer da instrução probatória, restou provado nos autos que o crime não ocorreu na modalidade tentada, vez que o réu, no momento de sua abordagem pela polícia, já se encontrava com a posse mansa e pacífica dos objetos furtados (14 (quatorze) pares de brinco, 5 (cinco) pingentes, 1 (um) relógio, 2 (dois) broche, 1 (um) colar de perola, 1 (uma) tesoura de unha e 1(um) chaveirinho, avaliadas em R\$ 300,00 (trezentos) reais, porquanto já o havia deslocado de seu local original sem que o proprietário percebesse e pudesse esboçar reação para reavê-lo. Nesse sentido, após o réu estar em posse dos bens de propriedade da vítima, foi abordado pelos policiais militares, os quais averiguaram os produtos de furto no interior da mochila de propriedade do réu, estando, portanto, o crime de furto consumado. Nesse

sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLATAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONSIDEROU APTA A DENÚNCIA. SUPERADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. TESE DE TENTATIVA DE FURTO. PARA A CONSUMAÇÃO DO FURTO É SUFICIENTE QUE O AGENTE TENHA A POSSE DA COISA, AINDA QUE NÃO SEJA MANSO E PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória, "isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal." (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015).

2. Quanto à suposta ofensa ao artigo 14, II, do Código Penal, tem-se que tal pleito não merece subsistir, porquanto o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a consumação do furto, basta que o agente tenha a posse da coisa, ainda que não seja manso e pacífico. Precedentes.

3. Portanto, incide à hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

4. Agravo regimental não provido. ".

(AgRg nos EDcl no AREsp 1033354/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

Assim prevê o artigo 383 do Código de Processo Penal.

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Trata-se do instituto emendatio libelli, pelo qual o magistrado fica autorizado a modificar a capitulação jurídica dos fatos e o momento oportuno para tal análise e alteração é na sentença.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS Nº 576.971 - AC (2020/0098456-1) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE RODRIGO ALMEIDA CHAVES - R0003684 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE PACIENTE : DONIZETE CUSTODIO DE LIMA INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Donizete Custodio de Lima, em que se aponta como autoridade coatora a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por ter, segundo a denúncia, junto com outro agente, tentado subtrair dois pneus, marca Pirelli, pertencentes à Polícia Civil, não ocorrendo o delito por circunstância alheia à sua vontade. Na sentença, o réu foi condenado, pelo crime consumado de furto, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 59 dias-multa (fls. 213/227). Em sede de apelação (n. 0005087-71.2016.8.01.0001), a defesa apontou nulidade na sentença, ao argumento de ofensa ao princípio da correlação. De forma alternativa, requereu a reforma na dosimetria da pena. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre negou provimento ao recurso (fls. 260/272). No presente writ, a defesa aponta violação do princípio da correlação na condenação do paciente (fls. 3/12). Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (fls. 292/294). É o relatório. Razão não assiste à defesa. A denúncia descreveu a conduta com a capitulação jurídica relativa à tentativa de furto, no entanto, pelo que consta do acórdão hostilizado, durante a audiência de instrução e julgamento, o titular da ação penal verificou que o paciente havia sido encontrado na posse dos bens furtados, de modo que o Magistrado procedeu à emendatio libelli. Confira-se trecho do voto estadual (fls. 267/268 - grifo nosso): [...] Em que pese

os argumentos defensivos, eles não merecem acolhida, conquanto muito embora o Recorrente haja sido denunciado pela prática do crime previsto no Art. 155, §§ Io e 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II. do Código Penal (furto qualificado em sua forma tentada), no curso da instrução criminal o titular da ação penal (na audiência de instrução e julgamento) observou que o crime foi cometido em sua forma consumada, conquanto o Recorrente restou flagrantado na posse da res furtiva, o que aponta para a ocorrência da inversão da posse dos objetos furtados, tendo o magistrado concordado (p. 210). Desse modo, a meu sentir, o magistrado de piso aplicou o princípio do emendatio libelli, previsto no Art. 383, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na inicial acusatória ou na queixa crime, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, venha aplicar pena mais grave. Noutras palavras, os fatos pelos quais o réu foi denunciado e aqueles analisados pelo Juiz continuam os mesmos, apenas ocorrendo uma alteração na interpretação quanto à tipificação. Em síntese, o instituto significa dar ao fato definição jurídica diversa (mudar o artigo de lei - tipificação), sem modificar a descrição de fato contida na denúncia ou queixa. A correção da capitulação legal pode ser feita mesmo que implicar aplicação da pena mais grave. Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "A validade da correção da capitulação do crime na sentença tem, pois, um pressuposto: a completa adequação (subsunção) do tipo penal então aplicado pelo juiz aos fatos narrados na acusação. Se o novo tipo penal, isto é, se a nova definição jurídica dos fatos contiver elementos não descritos na denúncia, além daqueles outros nela incluídos, não se poderá fazer a emendatio (2014, p.775). Assim, se o juiz decidir realizar a emendatio libelli na sentença ou na decisão de pronúncia, poderá fazê-lo diretamente, sem a necessidade de aditamento da denúncia ou manifestação prévia das partes, já que incumbe ao acusado defender-se dos fatos, independente da definição jurídica a eles atribuída, consoante preleciona o princípio da consubstanciação. [...] Não há ilegalidade nesse ponto, pois os fatos considerados pelo Juízo de primeiro grau, na sentença proferida, guardam estrita correlação com aqueles descritos na denúncia e que foram observados também na audiência de instrução e julgamento. A propósito: [...] A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à emendatio libelli, conforme autoriza o artigo 383 do CPP. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, procedendo a emendatio libelli. [...] (AgRg no AREsp n. 1.637.200/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020) Ante o exposto, denego a ordem. Publique-se. EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VERIFICADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE O PACIENTE TEVE A POSSE DOS BENS. CRIME CONSUMADO. Ordem denegada. Brasília, 27 de maio de 2020. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 576971 AC 2020/0098456-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 29/05/2020)

Assim, diante das robustas provas produzidas nos autos, comprovada materialidade, autoria e dolo, a condenação do réu é a medida que se impõe.

Passo, pois, a dosagem da pena.

A) Pena-base: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não é portador de maus antecedentes conforme observado em sua folha de antecedentes de fls. (113/117) e certidão de fls. 118/120.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o réu é reincidente em crime doloso

(Execução Criminal 0023674-25.2016.8.26.0041), e praticou o crime durante a pandemia da Covid-19 (artigo 61, II, "j"), razões pelas quais exaspero a pena em 1/5, resultando em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa.

C) Causas de aumento e de diminuição: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa, unidade igual a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena: não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, entendendo que embora o réu não seja reincidente específico, as medidas não seriam socialmente recomendáveis, posto que não é a primeira vez que o réu responde por delito contra o patrimônio, estando em situação de rua e drogadição.

E) Regime de cumprimento da pena: não obstante seja a pena fixada abaixo de 4 anos, o réu é reincidente em crime doloso, razão pela qual fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena reclusiva (CP, art. 33).

D) Liberdade: Tendo em vista que respondeu o processo todo preso, não vislumbro motivos para colocar o réu em liberdade, agora com sentença condenatória.

Por todo o exposto e tudo mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu VICTOR HUGO DE FREITAS RIBEIRO como incurso no artigo 155 caput do Código Penal, razão pela qual o condeno à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa, com valor unitário no mínimo legal, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme retro detalhado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se mandado de prisão condenatório e guia de recolhimento provisória.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Francisco Morato, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA